

1500876-98.2019.8.26.0070

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Fato Atípico

Magistrado: Aline de Oliveira Machado Bonesso Pereira de Carvalho

Comarca: Batatais

Foro: Foro de Batatais

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/10/2022

... conjunto Zaira Pupim, visto que lá o tráfico de drogas é muito intenso e que estaria havendo hostilidades da população local contra os policiais militares. Relatou que o acusado é conhecido pelo envolvimento com o tráfico de drogas, além de ser um dos líderes do tráfico daquela região. Aduziu que João Marcos estava muito apreensivo e que, quando Fracaroli veio na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Batatais

Foro de Batatais

Vara Criminal

Praca Dr. José Arantes Junqueira, 01, Batatais-SP - cep 14300-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500876-98.2019.8.26.0070 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500876-98.2019.8.26.0070

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Fato Atípico

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2302086/2019 - DEL.POL.BATATAIS, 4976757 - DEL.POL.BATATAIS, 1800/19/323 - DEL.POL.BATATAIS, 2302086 - DEL.POL.BATATAIS, 1800/19/323 - DEL.POL.BATATAIS, 2302086 - DEL.POL.BATATAIS, 1800/19/323 - DEL.POL.BATATAIS, 2302086 - DEL.POL.BATATAIS, 1800/19/323 - DEL.POL.BATATAIS, 2302086 - DEL.POL.BATATAIS, 1800/19/323 - DEL.POL.BATATAIS, 2302086 - DEL.POL.BATATAIS, 1800/19/323 - DEL.POL.BATATAIS, 2302086 - DEL.POL.BATATAIS, 1800/19/323 - DEL.POL.BATATAIS, 2302086 - DEL.POL.BATATAIS, 1800/19/323 - DEL.POL.BATATAIS, 2302086 - DEL.POL.BATATAIS, 1800/19/323 - DEL.POL.BATATAIS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOAO MARCOS SILVA SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Aline de Oliveira Machado Bonesso Pereira de Carvalho

Vistos.

JOÃO MARCOS SILVA SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da lei nº 11.343/06, porque, no dia 19 de junho de 2019, durante

o período noturno, no Condomínio Zaira Pupim, nesta cidade e comarca de Batatais/SP, trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de tráfico, a quantidade de 10,60g (dez gramas e sessenta miligramas) de cocaína acondicionada em 28 (vinte e oito) microtubos de plástico preto; 2,19g (dois gramas e dezenove miligramas) de crack acondicionados em 13 (treze) invólucros de plástico incolor; e 10,20g (dez gramas e vinte miligramas) de maconha acondicionados em 09 (nove) invólucros de plástico incolor, conforme laudo químico toxicológico (fls.18/20), substâncias estas que causam dependência física ou psíquica.

Boletim de Ocorrência (fls. 05/06).

Laudo Pericial da droga apreendida (fls. 18/20).

Laudo pericial de imagens gravadas no local (fls. 38/60).

Notificado, o réu apresentou a defesa Preliminar (fls. 135/147).

A denúncia foi recebida em 08 de outubro de 2020 (fls. 175/177).

Durante a instrução, foram ouvidas quatro testemunhas arroladas pela acusação, quatro pela defesa e, por último, o réu foi interrogado.

Em memoriais, o Ministério Público pleiteou a condenação do réu nos termos da denúncia. A defesa, por seu turno, requereu a absolvição do réu nos termos do art. 386 do Código de Processo Penal.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido formulado na ação penal deve ser julgado procedente.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 05/06), pelo Laudo Pericial (fls. 18/20), bem como pela prova oral coligida.

A autoria, do mesmo modo, restou demonstrada nos autos.

Em juízo, a testemunha Ricardo Borges Fracarolli, policial militar, disse que ele e o policial militar Alessandro Suzini realizavam patrulhamento, quando, ao adentrarem pelo conjunto Zaira Pupim, avistaram João Marcos entre os blocos, no corredor em que normalmente é realizada a venda de drogas. Disse que, assim que o réu viu a viatura, jogou um objeto atrás dos blocos e saiu correndo. Declarou que seu parceiro desembarcou e saiu na tentativa de encontrá-lo e abordá-lo. Aduziu que João Marcos foi abordado no bloco de trás, de número 71, e que na abordagem não encontraram nada de ilícito com o acusado. Relatou que foi procurar o que o acusado havia arremessado, encontrando os entorpecentes. Aduziu que, em razão de ter conhecimento de que o acusado era envolvido com o tráfico de drogas, e de que os moradores do local dificultam a ação policial, solicitou apoio. Declarou que formou um tumulto entre os moradores e que João Marcos estava gritando e se exaltando a fim de chamar a atenção dos populares e de outras pessoas envolvidas com o crime, que cercaram toda a equipe policial. Aduziu que, após encontrar as drogas e retornar, fez um sinal para o seu companheiro de que tinha encontrado os entorpecentes e que João Marcos, ao perceber isso, conseguiu sair da contenção dos policiais e correu, não sendo possível acompanhá-lo em razão do tumulto que havia se formado. Informou que na ocasião havia uma pessoa chamada Luciana, que filmava e xingava os policiais. Disse que o local é um ponto forte de tráfico de drogas na cidade e que os fatos ocorreram no período noturno, porém ele e o tenente Suzini viram claramente o réu dispensando o objeto, porque a distância era pequena. Aduziu

que na primeira abordagem estava apenas ele e o tenente Suzini e que, logo em seguida, chegaram as viaturas de apoio, tendo a ocorrência demorado mais que trinta minutos, mas não se lembra o tempo exato. Disse que foi possível ver a direção em que foi arremessado o entorpecente, e que o acusado estava sozinho quando dispensou o objeto.

No mesmo sentido foram as declarações da testemunha Alessandro Suzini, policial militar que presenciou a ocorrência, aduzindo ainda que o acusado é um dos líderes do crime organizado na região onde foi realizada a abordagem, e que Luciana estava incitando as pessoas a tumultuar a ação policial.

Em juízo, a testemunha Danilo Luiz Dias Miguel, policial militar, disse que foi solicitado apoio pela viatura que se encontrava no local. Declarou que ele e seu parceiro ficaram na contenção de João Marcos e que Fracarolli encontrou os entorpecentes, tendo João Marcos se evadido quando percebeu que havia sido encontrada a droga. Relatou que a população estava tumultuando o local e atrapalhando o trabalho policial, bem como que Luciana efetuava gravações com celular, ameaçando a equipe policial, além de instigar a população contra os policiais. Aduziu que Luciana é sogra de João Marcos. Relatou que não sabe se Luciana gravou toda a operação policial. Informou que o acusado é bastante conhecido e é envolvido com o tráfico de drogas.

Em juízo, a testemunha Rodrigo Tristão Museti, policial militar, disse que, no dia dos fatos, foi chamado para auxiliar na operação no conjunto Zaira Pupim, visto que lá o tráfico de drogas é muito intenso e que estaria havendo hostilidades da população local contra os policiais militares. Relatou que o acusado é conhecido pelo envolvimento com o tráfico de drogas, além de ser um dos líderes do tráfico daquela região. Aduziu que João Marcos estava muito apreensivo e que, quando Fracaroli veio na direção deles com um pote branco em mãos, o réu saiu correndo, se evadindo, não sendo possível abordá-lo devido a aglomeração de pessoas que havia no local. Declarou que uma mulher chamada Luciana, que sempre atrapalha o trabalho dos policiais, estava xingando os agentes e incitando a população.

Em juízo, a testemunha Alessandro de Paula Tostes Silvestres, policial militar, disse que participou da ocorrência, permanecendo na segurança da viatura, pois no local já houve casos de depredação de viaturas. Declarou que no momento em que João Marcos percebeu que os policiais haviam encontrado a droga que ele havia dispensado, saiu correndo, se evadindo.

Em juízo, a testemunha Willian Mariani, policial militar, disse que foi apoiar as demais viaturas no local, sendo sua viatura a última a chegar. Relatou que o acusado já havia sido abordado, estando alguns policiais em volta, tendo começado a aglomerar várias pessoas. Aduziu que Fracaroli encontrou o entorpecente que havia sido dispensado pelo acusado, momento em que ele empurrou os policiais e saiu correndo, enquanto uma mulher chamada Luciana e outras pessoas tumultuavam o local. Relatou que posteriormente tiveram outras ocorrências envolvendo o acusado, que se denominava como "chefe do tráfico". Disse que o maior tumulto foi posterior à fuga do acusado, que foi quando Luciana começou a incitar muito a população, sendo que a "pior" parte da ocorrência Luciana não filmou. Declarou que nas outras ocorrências que fez com envolvimento de João Marcos, não encontrou com ele nenhuma droga. Aduziu que o acusado já ameaçou o cabo Fracaroli e sua família após essa ocorrência.

Em juízo, a informante Luciana Aparecida Correia, sogra do réu, disse que, no dia dos fatos, estava tendo um ensaio das crianças para uma festa junina que iria ocorrer no conjunto habitacional e que seu genro João Marcos também estava ali, presenciando o ensaio junto com alguns amigos dele. Relatou que entrou uma viatura, que chegou próxima de onde João Marcos estava e o levou para a terceira rua, onde realizaram busca pessoal nele, fazendo ele tirar o tênis, a meia, a jaqueta e,

então, Fracarolli disse que iria fazer uma busca pelo local porque não haviam encontrado nada com João Marcos. Declarou que começou a gravar, pois anteriormente os policiais já haviam ido até a casa de João Marcos e quebrado a porta. Informou que Fracarolli voltou sem nada e saiu de novo para procurar pela droga. Disse que seguiu Fracarolli, filmando com seu celular, tendo ele entrado em um beco que já havia ido antes, saindo do outro lado, pelos fundos, com uma sacola branca que ele pegou do chão. Relatou que Fracarolli encontrou algo e foi mostrar para Suzini que estava na viatura, aduzindo que quando seu genro viu isso, saiu correndo. Salientou que não é envolvida com tráfico e que é muito perseguida por esses policiais. Disse que em nenhum momento xingou os policiais e nem incitou a população. Somente estava gravando para que eles não "forjassem". Declarou que havia muitas pessoas ali perto dos policiais e de João Marcos, porém elas estavam apenas observando, e em nenhum momento essas pessoas xingaram ou atrapalharam os policiais. Informou que trabalha vendendo lingerie e também fazendo marmitas.

Em juízo, a testemunha Rodrigo Marcelo Silveira Cocito, policial civil, disse que não teve muito trabalho investigativo depois da ocorrência, que foi encaminhada até ele para a realização de algumas diligências. Relatou que notou uma divergência entre o que foi dito pelos condutores da ocorrência com relação às imagens, e isso foi relatado ao delegado, para que este fizesse seu próprio juízo de valor. Disse que constatou que, alguns meses antes, o policial militar Fracarolli tinha registrado uma ocorrência de desacato contra João Marcos, onde João Marcos teria dito que fazia parte do "157" e não do tráfico e que receberia os policiais com tiros no Zaira Pupim. Relatou que não sabe o resultado da perícia do vídeo e que na época apenas constatou que havia algumas divergências entre o conteúdo do vídeo e o depoimento dos policiais, e que acredita que se o vídeo fosse editado o perito teria constatado. Aduziu que achou a fuga do acusado estranha naquelas circunstâncias. Declarou que tinham denúncias vindas de policiais que essa senhora chamada Luciana estaria envolvida com o tráfico, porém, pelo que se recorda, nada foi comprovado nesse sentido. Salientou que algumas vezes já aconteceu de na investigação policial se constatar como verdade o contrário do que foi dito pelos policiais militares, pois a convicção às vezes falha e os policiais podem cometer erros. Informou acreditar que a gravação que chegou ao conhecimento da polícia civil foi de apenas uma parte da operação policial, após a abordagem. Disse que o vídeo gravou o momento em que João Marcos tomou conhecimento de que tinham encontrado uma droga, tendo ele empreendido fuga. Questionado, respondeu que o réu foi abordado muito próximo de onde ele estava na cerca, porém quando alguém empreende fuga, a pessoa não para de correr e não fica aguardando a abordagem. Além disso, disse que ele foi capturado depois de uma perseguição e não foi devidamente detido neste momento, o que deveria ter sido feito. Avaliou que o vídeo demonstra que o réu estava aparentemente tranquilo. Indagado, respondeu que as discrepâncias que ele entende que ocorreram, pelas imagens que ele viu no vídeo, tratam-se de seu juízo de valor, sua convicção pessoal.

Ao ser interrogado em juízo, o réu João Marcos Silva Santos disse que os policiais mentiram, pois no dia dos fatos estava ajudando na festa junina, momento em que a viatura chegou e o policial Fracarolli pediu para que ele encostasse na parede que iria ser abordado, o que ele fez. Relatou que foram mais para baixo, no bloco 71, onde Fracarolli começou a perguntar para ele quem é que tinha corrido, oportunidade que ele respondeu que não tinha visto nada, e que só estava ajudando na festa. Declarou que neste momento sua sogra, Luciana, começou a filmar a operação, e que ele se encontrava sem algemas, cooperando, enquanto os policiais rondavam o local procurando por algo. Disse que Fracarolli chegou e disse para ele "é João Marcos, não foi dessa vez", e o policial Suzini disse que eles iriam libera-lo, mas que precisavam de seu RG, tendo sua mulher buscado o documento e apresentado aos policiais. Aduziu que em nenhum momento correu, mas aguardou os policiais. Sustentou que já teve algumas desavenças com o policial Fracarolli. Disse que já havia encerrado a ocorrência e que já iriam liberar ele, quando Fracarolli entrou no fundo, em um lugar no escuro e saiu fazendo gestos, e que, quando viu a droga na

mão dele, já saiu correndo porque estava com medo, pois essa droga não era sua. Disse que nunca teve qualquer problema com nenhum outro policial, apenas com Fracarolli. Relatou que a ocorrência se deu por conta das desavenças que já tinha com Fracarolli, que, em uma outra oportunidade, teria tentado prender ele, porém não conseguiu, tendo o ameaçado dizendo que a hora dele iria chegar. Finalizou dizendo que a população não xingou e nem tumultuou a ocorrência em nenhum momento, e que posteriormente, os policiais continuaram a tentar incriminá-lo, apresentando drogas em seu nome.

Não obstante a negativa apresentada pelo réu, bem como o depoimento das testemunhas de defesa, entendo que, em análise a todo o conjunto probatório carreado nos autos, notadamente os depoimentos prestados pelas demais testemunhas, os elementos coligidos se revestem de coerência, robustez e segurança, sendo hábeis à condenação do acusado.

Primeiramente, saliento que não se demonstrou que os policiais militares que participaram da ocorrência tivessem razões próximas ou remotas para se unirem e, deliberadamente, imputarem ao acusado a prática de um crime tão grave.

Sobre a credibilidade dos depoimentos dos policiais, destaco julgado do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"É bem sabido que não furta a lei validade aos depoimentos de policiais, tanto que sequer os isenta do compromisso de dizer a verdade, nem os poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, se vierem a sonegar a realidade dos acontecimentos. Ao juiz, o que cumpre é conferir a tais declarações o justo e merecido valor, cotejando-as e confrontando-as com os demais elementos de convicção, conferindo-lhes, ou não, segundo seu livre poder de convencimento, o merecido poder de persuasão. Não se compreende, na verdade, seja a atividade policial desprovida de um mínimo de eficiência, de ética, de veracidade a ponto de se arvorar em incriminadora insensata de inocentes. Nem teria sentido conferir a lei determinada tarefa ao agente de segurança para, ao depois, quando fosse ele convocado a prestar contas de sua atuação, negar-lhe valor aprioristicamente, por preconceituosa admissão de que não diz a verdade". (TJSP, Apelação Criminal nº 112.195-3/1, Rei. Des. Canguçu de Almeida).

No caso, os testemunhos dos policiais mostraram-se plenamente críveis, eis que, tanto em polícia como em juízo, discorreram sobre a dinâmica dos fatos sempre da mesma forma, máxime quanto ao cerne, ao conteúdo da acusação.

Como se nota, o acusado foi visto pelos policiais Fracarolli e Suzini dispensando algo e saindo do local onde inicialmente estava, sendo abordado ali próximo, tendo os entorpecentes sido encontrados pelo policial Fracarolli onde o réu foi inicialmente avistado dispensando algo, no caso, as drogas.

Deste modo, diante de tais circunstâncias em que se deu a operação, pelos relatos dos policiais que abordaram o acusado, está devidamente comprovado que ele cometeu o delito que se apura, sendo os elementos probatórios suficientes para comprovação de sua responsabilização penal.

Frisa-se aqui que a circunstância da droga ter sido encontrada com demora ou não, de o policial necessitar procura-la por breve ou amplo período de tempo, indo e voltando, não é capaz de afastar o fato de que os entorpecentes foram encontrados no local em que o acusado foi avistado dispensando-os.

Saliente-se aqui que, inobstante a argumentação levantada pela defesa do réu, destaco que não foi apresentada nenhuma prova de que ele teria sido vítima de uma suposta "armação" por parte do policial Fracarolli, ônus que lhe competia, por força do disposto no artigo 156, do Código de Processo Penal. Sem a referida prova, as alegações do réu restam vazias e em nada o socorrem.

Saliente-se, ainda, que a palavra dos policiais merece a mesma credibilidade conferida à do particular. A presunção que se costuma fazer, no sentido de que a palavra do policial sempre tem por escopo justificar sua ação, não guarda sintonia com a realidade, competindo ao réu a prova de tese editada a respeito. A propósito, não se pode presumir que a ação do policial, investido pelo Estado em função de vigilância e repressão, tenha por destinação a incriminação de um cidadão inocente. Seria preciso, para tanto, a existência de indícios mínimos a respeito. E a prova colhida, insisto, não revela qualquer traço de irregularidade na conduta dos policiais. (TJSP; Apelação 0004625-56.2016.8.26.0248; Relator (a): Pinheiro Franco; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Indaiatuba - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 16/08/2018; Data de Registro: 16/08/2018) (destaquei).

Neste ponto convém ressaltar que a gravação apresentada pelo réu, que foi objeto de laudo pericial, não contemplou a abordagem completa, do início ao fim, bem como não demonstra nenhuma atuação policial com intuito de incriminá-lo.

Na verdade, referida gravação confirma os testemunhos prestados pelos policiais que realizaram a abordagem, já que, em ordem cronológica, observa-se que em um primeiro momento o acusado se encontrava em abordagem, depois os entorpecentes são procurados e encontrados pelo agente policial, e, após, quando chegou com a droga ao local da abordagem, o acusado empreendeu fuga, momento em que o vídeo foi encerrado, conforme laudo pericial produzido na fase policial.

É pertinente destacar aqui que, em relação ao depoimento do policial civil Rodrigo Cocito, observa-se que as conclusões por ele obtidas partem da análise das imagens juntadas aos autos, que, conforme já mencionado, não apresentaram a operação policial completa, mas apenas parte dela.

Ademais, a própria testemunha, ao ser questionada, respondeu que as divergências que ele entendia que ocorreram, em análise às imagens, tratam de seu juízo de valor, sua convicção pessoal.

Sendo assim, não há como serem considerados como elementos de prova capazes de acolher a tese defensiva de que o réu teria sido vítima de uma suposta "armação" por parte do policial Fracarolli eventuais juízos de valor explanados pelo policial civil, que sequer participou da ocorrência, tendo apenas realizado uma análise das imagens de parte da operação.

Portanto, não restou comprovada a tese levantada pela defesa de que o réu teria sido vítima de uma acusação forjada pelos policiais. Pelo contrário, repise-se, os elementos probatórios angariados nos autos demonstraram, com clareza e robustez, a prática da conduta delitiva pelo acusado, sendo sua condenação medida de rigor.

O elemento subjetivo do tipo, do mesmo modo, restou comprovado.

E isto porque o tráfico de entorpecentes é crime de perigo abstrato, bastando, para sua consumação, a mera probabilidade de dano à saúde das pessoas.

Sendo assim, para a caracterização do aludido delito, basta que o agente aja com dolo de perigo, isto é, a deliberada intenção de colocar em risco o bem jurídico à tutela da saúde pública. Em outras palavras, basta a vontade livre e consciente de realizar uma das condutas previstas no art. 33, da Lei n. 11.343/06.

Nesse sentido, confira-se: "O tipo penal de tráfico é de conteúdo variado ou misto alternativo, pois qualquer das condutas descritas tipifica o delito. Assim, mesmo que o agente não tenha comercializado a droga, a simples guarda é suficiente para que se configure o tráfico de entorpecentes" (TJRS, Ap. 697.020.717, 1ª Câmara. j. 30-4-1997, rel. Des. Érico Barone Pires, RT 745/633).

Vale consignar, ainda, que a quantidade, a variedade e a forma como estavam acondicionadas as drogas apreendidas (na forma de pequenas porções uniformes, acondicionadas em cápsulas ou embaladas em invólucros de plástico, já fracionadas para posterior venda), além da forma em que se deu operação (em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, conforme a prova oral colhida em juízo), demonstram, com clareza, que os entorpecentes destinavam ao comércio.

Deste modo, cabais e indubitadas tanto a materialidade quanto a autoria, destaco que o fato é típico e ilícito, e o réu é culpável, razão pela qual a condenação pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 é medida que se impõe.

Passo, pois à dosimetria da pena.

Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, e as circunstâncias preponderantes do art. 42 da LD, observo que foi apreendida grande variedade de drogas, o réu é portador de maus antecedentes, além de ser reincidente, circunstância esta que será considerada na segunda fase. Assim, sendo as circunstâncias judiciais desfavoráveis fixo a pena-base em 5 anos e 10 meses de reclusão, além do pagamento de 583 dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes a serem consideradas. Presente a agravante da reincidência, conforme se depreende de fls. 319/321, majoro a reprimenda inicial, perfazendo 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, além do pagamento de 680 dias-multa.

Já na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição, torno definitiva a pena no patamar fixado na fase intermediária.

Observo não ser o caso de reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, tendo em vista que, conforme se observa pela folha de antecedentes do acusado, ele está respondendo por outro delito, inclusive de tráfico de drogas, podendo concluir-se que se dedica à prática de atividades criminosas, não preenchendo assim os requisitos para caracterização do tráfico privilegiado. Ademais, os policiais ouvidos informaram que o réu possui envolvimento com tráfico de drogas, o que não recomenda a aplicação de tal benesse. Além disso, o réu é reincidente.

A finalidade desta minorante é adequar a punição ao caso concreto, atendendo-se ao princípio constitucional de individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal) e adequar a pena prevista no preceito secundário do artigo 33, "caput", ao fato delituoso que represente menor gravidade. Ou seja, reduzida ofensa, menor perigo social, uma vez que se dirige as pessoas que não tenham envolvimento anterior com crimes e que, a despeito de terem praticado uma conduta relacionada ao tráfico de drogas, não se dediquem à traficância, o que não se verifica in casu.

Nesse sentido, cumpre trazer à baila brilhante lição sobre o tema, em acórdão da lavra do i. Desembargador Geraldo Wholers (Apelação nº 0427092-39.2010.8.26.0000 - 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo):

"O propósito do legislador, certamente, não foi favorecer os traficantes de alto coturno. A mens legis da Lei nº 11.343/06 há de ter tido em vista, primordialmente, fornecedores ocasionais, que não denotam perseverança criminosa, hábito delinquencial ou gravíssimo comprometimento para a ordem social, a paz coletiva e a saúde da população em geral, virtudes certamente irreconhecíveis no imperdoável traficante de drogas que persevera nessa senda. Tanto, aliás, que o citado art. 33, § 4º, contém expressa referência, para fins de merecimento da redução condescendente, à exigência de que o agente "não se dedique às atividades

criminosas". Sabe-se que em termos repressivos o ditame constitucional é o de desestimular com energia o comércio ilegal de drogas; logo, o benefício trazido pela nova lei de regência, editada sob o mote de tornar mais rigoroso o tratamento penal que incide sobre o traficante, conflita, quando aplicado de modo indiscriminado, com a Constituição da República. Há, além da quebra do princípio de isonomia entre os condenados por outros crimes (especialmente pelos classificados como igualmente hediondos) e os condenados por tráfico de drogas, uma violação às disposições constitucionais e aos tratados internacionais que obrigam o Poder Público brasileiro à repressão efetiva do narcotráfico. A inteligência útil e legítima da norma sob análise só pode ser feita à luz da Carta Política, e nesse passo se conclui que a mercê foi estabelecida para dar solução excepcional a situações excepcionais. No âmbito desta Colenda Câmara, registrou o preclaro DES. LUIZ ANTÔNIO CARDOSO por ocasião do julgamento da Apelação Criminal nº 990.09.111160-0 (Comarca de Lucélia, j. em 25 de maio de 2010), que "essa causa de redução da pena deve incidir na excepcionalidade, em situações específicas, próprias, quando patente que o tráfico apurado cuidou-se apenas de um desvio na vida do réu, e não de uma contumácia, estilo, repetição de fato análogo, de uma rotina de proceder". A lei atual trouxe tratamento distinto para quem oferece droga a pessoa de seu relacionamento sem objetivo de lucro - a rigor, traficante de entorpecentes: § 3º do mesmo artigo 33. Ora, também se reserva tratamento diferenciado no § 4º, pois o redutor se dirige a quem comete uma das condutas puníveis constantes do caput ou do § 1º do artigo 33 quando o agente atua sem ter o lucro por meta, sem intuito de comércio, sem adotar a odiosa e desagregadora propagação narcótica como meio de vida. É assim que se deve considerar a exigência de "não se dedicar às atividades criminosas" (terceira figura dos pressupostos indispensáveis à concessão da benesse), porque quem procura obter vantagem financeira através do mercadejo de substância clandestina se propõe, claro, a exercer atividade criminosa: presta o torpe serviço para alguém, faz a deplorável intermediação para alguém, busca aumentar os recursos ilícitos de grupos ou organizações formadas à margem da lei para custear investidas delituosas n'outros setores do submundo. Convenhamos ser fenômeno de extrema raridade o traficante que age solitariamente... Se se der outra interpretação ao dispositivo em apreço, de forma a alcançar todo e qualquer agente que preencha os demais requisitos, haverá incontornável discrepância com outras normas da mesma Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, como, por exemplo, a descrição típica de seu artigo 37 (mero informante)".

Destarte, fixo a pena definitiva em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, além do pagamento de 680 dias-multa.

Considerando que não há nos autos informações acerca das condições econômicas do condenado, fixo cada dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato (art. 43 da Lei 11.343/06).

O regime de cumprimento de pena privativa de liberdade deverá ser, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, o regime fechado, haja vista a quantidade da pena fixada e ser o réu reincidente. Assim, somente regime mais gravoso poderá atender ao princípio da individualização da pena, especialmente diante das circunstâncias do caso concreto, notadamente a relevante quantidade e variedade de drogas apreendidas, em local reconhecido pela prática delitiva de tráfico. Ademais, trata-se de réu reincidente, o que, por si só, já justificaria a fixação do regime mais gravoso.

Não há que se falar em aplicação dos artigos 44 e 77, do Código Penal, em razão da quantidade da pena fixada.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o acusado JOÃO MARCOS SILVA SANTOS, como incurso no artigo 33, caput, da lei nº 11.343/06, à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial



fechado, além do pagamento de 680 dias-multa, no valor mínimo unitário de 1/30 do salário mínimo, que deverá ser atualizado da data dos fatos até efetiva liquidação.

Permito o apelo do acusado na situação em que se encontra, pois até o presente momento, nenhum fato novo surgiu que pudesse indicar a necessidade de decretar novamente sua prisão preventiva, bem como inexistente provocação da acusação nesse sentido. Desse modo, assegurado está o direito recorrer desta sentença em liberdade.

Determino a incineração da droga apreendida, nos termos do artigo 58, §1º, cumulado com o artigo 32, § 1º, ambos da Lei 11.343/06.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, observada eventual justiça gratuita.

Após o trânsito em julgado, tomem-se as seguintes providências:

- a) Oficie-se ao TRE para os fins do art. 15, III, da CF;
- b) Oficie-se ao órgão responsável pelo cadastro de antecedentes;
- c) Expeça-se a competente guia de execução criminal e a encaminhe ao Juízo competente.

P.I.C.

Batatais, 19 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA